

1500829-84.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... o réu foi preso pelos GCMs em ponto de tráfico na posse de drogas e de dinheiro. Ademais, indicou aos GCM onde havia escondido centenas de entorpecentes. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denuncia. Outrossim, conforme demonstrado a fls. 67/69, item 6, bem como pelas declarações do GCM, praticava o tráfico de drogas em uma praça, onde inclusive ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500829-84.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2155320/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 2155320/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Severino Rosa

Réu Preso

Contr. nº 2022/000659

Aos 22 de agosto de 2022, às 14:50 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu JONAS SEVERINO ROSA (preso CPD Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s)

testemunha(s) comuns: GM Cesar Eduardo Bottene e GM Everton Ferreira de Jesus

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GM César) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) GM Everton, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). JONAS SEVERINO ROSA, está sendo processado como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III,, da Lei 11.343/06, pois no dia 07 de junho de 2022, por volta das 14h54, nas imediações da praça Agenor da Silva Pereira, situada na Rua Capitão Ricardo Mazzonetto, nº 544, Bairro Jardim São Jorge, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 2,0g de cocaína, distribuídos em 08 eppendorfs, 117,7g de cocaína, distribuídos em 416 eppendorfs, 4,4g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 54 invólucros e 203,7g de Cannabis sativa L. distribuídos em 139 invólucros¹, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentada (fls. 64/69). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 09/10, foto a fl. 18 e laudo pericial a fls. 78/81. Da mesma forma, comprovada a autoria delitativa. De fato, o GCM relatou, na fase informativa (fls. 02), que "data de hoje estava em patrulhamento na companhia do GCM Everton a bordo da viatura ROMU 08, quando em local já conhecido ponto de tráfico, Praça Agenor da Silva Pereira, onde havia uma senhora e três crianças brincando. Avistaram a aproximadamente uns vinte metros delas, sentado em um banco, um indivíduo e este ao avistar a viatura saiu correndo no sentido oposto da viatura. Após breve acompanhamento o abordaram a cinquenta metros do local e após busca pessoal o depoente encontrou em suas mãos oito pinos de cocaína, trinta reais em dinheiro e um aparelho celular marca Motorola. O identificaram como sendo Jonas Severino Rosa, questionado disse que estava no local vendendo drogas para pagar seu advogado. Jonas ainda indicou uma área verde próximo a praça, onde após diligências o depoente localizou uma bolsa azul escondida no meio do mato e dentro desta, haviam mais quatrocentos e dezesseis pinos de cocaína idênticos ao que estava em sua posse, cento e trinta e nove porções de maconha e cinquenta e quatro pedras de crack ". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que a praça é frequentada por crianças e pessoas do bairro. Na ocasião, havia crianças brincando na praça a cerca de 10 metros de onde o réu foi abordado. Ali também há um barracão, onde a comunidade faz atividades culturais. Informou que o réu disse que estava vendendo drogas para pagar o seu advogado. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o réu foi preso pelos GCMs em ponto de tráfico na posse de drogas e de dinheiro. Ademais, indicou aos GCM onde havia escondido centenas de entorpecentes. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denuncia. Outrossim, conforme demonstrado a fls. 67/69, item 6, bem como pelas declarações do GCM, praticava o tráfico de drogas em uma praça, onde inclusive crianças brincavam em um playground, situada no local dos fatos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar, na primeira fase, a grande quantidade de drogas (mais de 6 centenas de invólucros de drogas - foto a fls. 18). Na segunda fase, que o réu é reincidente específico (certidão a fls. 75/76), razão pela qual também não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e,

consequentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). JONAS SEVERINO ROSA vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o réu foi preso em flagrante após sofrer abordagem de guardas municipais, que teriam suspeitado de sua conduta, pois ao perceber a aproximação da viatura policial, ele teria se levantado do banco no qual sentado e andado em sentido oposto. Porém, realizada a abordagem e posterior revista pessoal, encontraram com o réu algumas porções de droga em dinheiro. Na sequência, ele teria confessado o delito e indicado onde havia mais drogas. Ou seja, diante do apurado, forçoso convir que há irregularidades, que invalidam todo o caderno probatório produzido em desfavor do réu, sobretudo quanto a natureza da diligência realizada pelos servidores municipais. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM a investigação de infrações penais ou a prática de policiamento ostensivo para coibi-las. E, no presente caso, ficou demonstrado que os servidores municipais atuaram como se fossem integrantes das forças policiais, o que contraria o dispositivo constitucional supracitado. Com efeito, depreende-se dos depoimentos dos guardas municipais que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos (conhecido como “ponto de venda”) quando decidiram abordar o réu em razão de conduta que entenderam suspeita. Neste cenário, não se pode dizer que qualquer do povo poderia agir o que tornaria a prisão legal (art. 301, do CPP), já que a captura foi precedida de atos, cuja atribuição pertence a agentes policiais. Não é tarefa da GCM a prática de policiamento ostensivo e a realização de atos investigativos como busca e revista pessoal. Os agentes municipais não estão autorizados a efetuar patrulhamento ostensivo visando combater o tráfico de drogas. Neste sentido, merece destaque recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Tráfico de Drogas – Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais – Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar – Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil – Prova ilícita – Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500260-53.2019.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).: E, como salientado nem há como dizer que eles atuaram amparados no que dispõe o artigo 301, do Código de Processo Penal. Afinal, essa hipótese é reservada para os casos em que o flagrante é claro ou visual. E não para as hipóteses em que a situação de flagrante delito é precedida de uma desconfiança e da prática de atos típicos de policiamento ostensivo e investigativo, como a busca pessoal. Dessa forma, ainda que os guardas tenham agido com boa-fé, a questão é que eles não poderiam ir além da atuação que é autorizada a qualquer do povo, nos termos da legislação processual penal. E, reitere-se, não se vê qualquer cidadão praticando os atos que os guardas civis praticaram no caso sob exame. Além disso, cabe destacar que os guardas não tem competência para a prática de busca pessoal para apuração de possível ilícito penal. Não se trata de ato que não está dentro das atribuições dos guardas municipais, consoante Constituição Federal (art. 144) e Código de Processo Penal

(art. 240 e seguintes). Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: "Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta uma arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). Mas não é só., pois ainda que os guardas possuíssem atribuição para a realização da busca pessoal, certo é que, no caso em apreço, também inexisteria justa causa para tanto, pois a simples fuga do réu não justificava a abordagem. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito". Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. 2. Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55.2021.8.02.0049 " (STJ - HC n. 737.075/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Assim, seja por um motivo ou por outro, não há a menor dúvida de que a conduta dos guardas, na hipótese, acabou violando o art. 144, do CF, bem como o artigo 244, do CPP, o que invalida toda a prova que foi produzida a seguir. Afinal, é evidente o nexó existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, por pura falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos guardas municipais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos, mormente porque o policiamento ostensivo e a repressão de crimes não são atribuições da Guarda Municipal. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação. Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência

ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância. Em favor do acusado também há a atenuante da confissão, pois informalmente teria admitido a prática criminosa e indicado o paradeiro das drogas aos agentes municipais. Na terceira etapa deve ser afastada a causa especial de aumento de pena, pois não há prova de que o réu praticava o tráfico com o fim de atingir os frequentadores do local. Segundo o que foi narrado pelos guardas municipais, existiam três pessoas na praça, mas estavam distantes do réu. Não basta, assim, a mera localização do acusado. Nessa linha:

"A mera proximidade geográfica com entidades e estabelecimentos, elencados no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, sem a comprovação de que a atividade de tráfico era voltada para os frequentadores ou usuários, ou mesmo, que o agente se beneficiava de tal proximidade, não caracteriza a causa de aumento em questão." (Apelação Criminal nº 0000289-23.2018.8.26.0544, V.U, rel. Angelica de Almeida, julgado em 10/04/2019). E também: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, além de petrechos para o seu acondicionamento - Condenação mantida - Afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que o fato de o crime ter sido praticado numa praça, por si só, não deve incidir essa majorante - Aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços) previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Possibilidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Apelo parcialmente provido para reduzir a pena, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva". (TJSP; Apelação Criminal 0001226-82.2012.8.26.0531; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2015; Data de Registro: 09/05/2015). Estão ainda presentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois não há indícios de que o réu se dedique a atividades criminosas. Tampouco está inserido em associação voltada ao crime. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o "tráfico privilegiado": "A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência" (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. E com o reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se possível, por consequência, a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, requer-se seja conferido ao acusado o direito de apresentar eventual apelação em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

JONAS SEVERINO ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 14,54 horas, nas imediações da Praça Agenor da Silva Pereira, situada na Rua Capitão Ricardo Mazzonetto nº 544, Bairro Jardim São Jorge, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 2,0g de cocaína, distribuídos em 08 "ependorfs", 117,7g de cocaína, distribuídos em 416 "ependorfs", 4,4g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 54 invólucros e 203,7g de "Cannabis sativa L." distribuídos em 139 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que os guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram na sobredita praça, conhecida como ponto de tráfico de drogas, o acusado, o qual, ao avistar a viatura, evadiu-se. Em razão

disso, abordaram-no e localizaram em sua posse 08 "ependorfs" de cocaína e a quantia de R\$30,00, oriunda do narcotráfico. Em seguida, realizaram diligências no local e localizaram escondidas as demais drogas acima descritas, pertencentes a ele e que se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 89). Defesa preliminar apresentada às fls. 92/93. Após, a denúncia foi recebida (fls. 95) e o réu foi citado às fls. 118.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito. Pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida próximo à uma praça e em área de lazer.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilegalidade na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de

segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

De fato, conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde diuturnamente é exercida tal atividade ilícita. Ao notar a presença da viatura, ele, que estava sentado, imediatamente tentou se evadir indo em direção contrária à que vinham os guardas municipais, o que permitiu a abordagem, pois havia claro indicativo de que estava realizando o tráfico de drogas no local. Com ele, foram encontradas 8 porções de cocaína, assim como uma quantia de dinheiro. O réu confessou aos guardas a prática delitativa e, ainda, indicou o local onde escondia os demais entorpecentes, onde efetivamente foram encontrados.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Neste sentido, jurisprudências:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO j. 05/10/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitativa legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada

a "apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 25/08/2020) - g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 06/08;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e fotografias de fls. 18;
- 3) Laudo de constatação de fls. 11/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls.

78/81, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas;

4) Imagens do local dos fatos, extraídas do google maps, comprovando-se a existência de uma praça.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejam os:

Na fase informativa (fls. 04), o réu não quis se manifestar.

Interrogado em juízo (gravação), disse que, no dia dos fatos, estava sentado na praça indicada na denúncia e portava uma porção de maconha e R\$ 20,00. Ali havia atividades de recreação para crianças. Não correu quando os guardas se aproximaram. Eles o abordaram e o colocaram na viatura. Perguntaram se queria negociar com eles, entregando-lhes uma "casa bomba" ou uma arma. Como não lhes forneceu o que queriam, eles pararam numa área de mata, pegaram uma sacola e o levaram para a delegacia, acusando-o do tráfico. Disse que não os conhecia anteriormente.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o guarda municipal César Eduardo Bottene declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento na companhia do GCM Everton quando, em local já conhecido como ponto de tráfico, na Praça Agenor da Silva Pereira, onde havia uma senhora e três crianças brincando num playground, avistaram o réu sentado em um banco, a cerca de dez metros delas. Disse que, ao avistar a viatura, o réu saiu correndo em sentido oposto ao que vinham. Suspeitando da atitude dele, seguiram-no com a viatura e o abordaram a 50 metros do local. Em suas mãos, encontraram oito pinos de cocaína, R\$ 30,00 em dinheiro e um aparelho celular marca Motorola. Questionado sobre o motivo de ter corrido, ele afirmou que estava ali vendendo drogas para conseguir dinheiro para pagar seu advogado, pois tinha saído há pouco tempo da cadeia e não conseguia emprego lícito. O réu ainda indicou uma área verde próxima (distante de 15 a 20 metros de onde ele estava postado, atravessando a rua da praça) como sendo o local onde escondia as drogas. Lá, encontraram uma bolsa azul, escondida no meio do mato, dentro da qual havia 416 pinos de cocaína, idênticos ao que estavam em sua posse, 138 de maconha e 54 pedras de "crack". Explicou que o local dos fatos é uma praça na qual há parquinho para crianças e um barracão que as pessoas da comunidade usam para dança e outras atividades de lazer. Informou que já se depararam inúmeras vezes com pessoas na prática do tráfico naquele local, afirmando que, toda vez que passam lá, há alguém traficando. Entretanto, não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) pelo guarda municipal Everton Ferreira de Jesus.

Anoto que os relatos dos guardas municipais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que não os conhecia anteriormente e que nada tinha contra eles.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em

homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos guardas municipais não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e guardava para fins de tráfico, 424 "eppendorfs" contendo cocaína, 54 invólucros de crack e 139 invólucros de "Cannabis sativa L.", substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos guardas municipais no sentido de que o réu estava sentado num banco da praça, em local muito conhecido como ponto de tráfico, e, ao avistar a viatura, tentou se distanciar do local do crime, o que motivou a abordagem e resultou no encontro de parte das drogas em seu poder, sendo o restante encontrado em um esconderijo que

ele próprio indicou.

Nesse contexto, não há como se dissociar do réu a posse dos entorpecentes, nem como se afastar a convicção de que seu destino era a entrega a terceiros.

Ademais o acusado confessou, no calor da diligência, que estava no local vendendo drogas para pagar seu advogado, pois havia saído há pouco tempo da prisão e não conseguia emprego lícito. Ele, ainda, indicou aos guardas onde estava escondido o restante dos entorpecentes, o que permitiu seu encontro, pois o esconderijo ficava em meio a uma mata distante de 15 a 20 metros de onde ele estava.

O destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias das diligências, mas também em razão da grande quantidade de drogas, sua diversidade e pelo fato delas estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografias fls. 18), o que é totalmente incompatível com a situação do mero usuário.

Outrossim, com o réu foi apreendido valor em dinheiro, totalizando R\$30,00, cuja origem lícita não foi comprovada, presumindo-se tratar de produto das vendas, até em razão das circunstâncias da diligência.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e

periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

A majorante também restou demonstrada, porque o crime foi cometido em praça pública, local de recreação, onde, inclusive, havia crianças brincando no momento dos fatos.

É evidente que o tráfico realizado em tal local atinge seus frequentadores, especialmente os jovens que usavam aquele local de recreação para dança e outras atividades de lazer, como explicou o guarda civil.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

A diversidade e a quantidade de drogas revelou-se mais expressiva que o que comumente se vê nesse tipo de tráfico.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo as penas-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (cf. processos criminais de nº 1500307-91.2021, fls. 37/38) e, por outro lado, a atenuante da confissão da autoria do crime, o que foi considerado como elemento de convicção para formação da culpa.

Tais circunstâncias se compensam e não alteram as penas na segunda fase.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida próximo à praça pública e em área de lazer (frequentada por diversas pessoas, adolescente e, inclusive, crianças que brincavam no momento dos fatos), imperioso o aumento das penas em mais 1/6, o que perfaz seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e, tratando-se de reincidência específica, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves